

Aqui o delegatário ingressa com ação judicial (perante o Poder Judiciário) para extinguir a permissão ou concessão em virtude do descumprimento do contrato por parte do Ente Federado delegante.

Abaixo as peculiaridades da rescisão do contrato administrativo.

- Processo judicial: para que o permissionário ou concessionário possa extinguir o contrato em virtude de inadimplemento do Ente Federado delegante, sempre será necessária a ação judicial, pois ele não pode deixar de prestar o serviço público por vontade própria.

Portanto, percebe-se que, enquanto o Poder Público pode rescindir o contrato administrativo unilateralmente (extinção unilateral do contrato: encampação e caducidade), sem participação do Poder Judiciário, o delegatário (permissão ou concessão) não pode fazer o mesmo (rescisão de maneira unilateral): o delegatário sempre precisará da anuência do Poder Judiciário (não incidência da *exceptio non adimpleti contrato*, abaixo).

- Trânsito em julgado: o permissionário ou concessionário somente poderá deixar de prestar o serviço público após o trânsito em julgado da decisão judicial que julga procedente seu pedido de rescisão do contrato administrativo.

- Não incidência da "exceptio non adimpleti contrato": no Direito Administrativo não incide a teoria da exceção do contrato não cumprido, segundo a qual uma das partes pode escusar-se de cumprir sua obrigação por não ter a outra cumprido com aquilo que lhe competia (art. 476, CC).

É por isso que o delegatário (permissionário ou concessionária), enquanto não obtiver uma decisão judicial transitada em julgado em seu favor, não pode deixar de prestar o serviço público (princípio da continuidade do serviço público).

Código Civil

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

e) Anulação (art. 53 da Lei Federal n.º 9.784/1999): anulação é a extinção do contrato de permissão ou concessão em virtude de vício de legalidade, decorrente do poder de autotutela da Administração Pública.

Conforme já estudamos, havendo ilegalidade – isso vale para o contrato administrativo e para todo e qualquer ato administrativo –, o Poder Público tem a obrigação (dever) de declará-la e, como consequência, anular o contrato administrativo de permissão ou concessão do serviço público, pois não é permitido à Administração Pública agir na ilegalidade, descumprindo o que as normas jurídicas determinam.

Lei Federal n.º 9.784/1999

Art. 53. A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos.

f) Falência, extinção, falecimento ou incapacidade: por fim, o contrato de permissão ou concessão de serviço público também restará extinto quando ocorrer falência, extinção, falecimento ou incapacidade do permissionário ou concessionário.

- Pessoa jurídica (permissão ou concessão): falência ou extinção da empresa, bem como falecimento ou incapacidade do titular da empresa individual.

- Pessoa física (apenas na permissão): falecimento ou incapacidade da pessoa física.

5.4. Efeitos da Extinção

Com a extinção da permissão ou concessão – seja a extinção ordinária (término do prazo contratual), seja a extinção extraordinária (encampação, caducidade, rescisão, anulação e falência, extinção, falecimento ou incapacidade) –, ocorrem os efeitos abaixo.

a) Bens reversíveis (art. 35, § 1º, da Lei Nacional n.º 8.987/1995): os bens reversíveis retornam ao Ente Federado delegante.

O edital e o contrato de permissão ou concessão irão prever quais são os bens reversíveis, que geralmente serão aqueles indispensáveis à prestação do serviço público.

Ex.: num contrato de concessão de transporte público, pode-se prever que serão reversíveis os ônibus, os pontos de espera dos passageiros, o sistema informatizado dos cartões de embarque...

- *Indenização (art. 36, da Lei Nacional n.º 8.987/1995):* se ainda não foram amortizados (pagos), o delegatário (permissionário ou concessionário) terá direito à indenização pelos bens que forem revertidos ao Ente Federado delegante.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 35. [...]

§ 1º Extinta a concessão, retornam ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.

Art. 36. A reversão no advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido.

b) Assunção do serviço público (art. 35, § 2º, da Lei Nacional n.º 8.987/1995): com a extinção da permissão ou concessão, o Ente Federado delegante terá a imediata assunção do serviço público.

Ou seja, o Poder Público passa a prestar o serviço público diretamente – salvo se já houver realizado outra licitação e contratado um novo delegatário.

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Art. 35. [...]

§ 2º Extinta a concessão, haverá a imediata assunção do serviço pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.

→ *Princípio da continuidade do serviço público:* percebe-se que tanto a reversão de bens quanto a assunção do serviço público decorrem diretamente do princípio da continuidade dos serviços públicos.

6. PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA (PPP)

Aqui vamos estudar regras específicas aplicáveis às PPP's.

Portanto, além das regras gerais vistas no tópico anterior sobre permissões e concessões (que são concessões comuns de serviços públicos), previstas na Lei Nacional n.º 8.987/1995, temos regras específicas para as PPP's, que foram trazidas pela Lei Nacional n.º 11.079/2004.

~~1. Centralização~~

~~2. Descentralização~~

~~2.1. Descentralização por serviços ou outorga legal~~

2.2. Descentralização por colaboração ou delegação

~~2.2.1. Permissão~~

2.2.2. Concessão

~~2.2.2.1. Concessão comum~~

~~2.2.2.1.1. Concessão de serviço público~~

~~2.2.2.1.2. Concessão de serviço público precedida de obra~~

2.2.2.2. Parceria Público-privada (PPP)

2.2.2.2.1. Concessão patrocinada

2.2.2.2.2. Concessão administrativa

~~3. Consórcios Públicos~~

a) Prazo de 5 a 35 anos (art. 5º, I, da Lei Nacional n.º 11.079/2004): as PPP's sempre devem ter um prazo de cinco a 35 anos de duração, o qual deve ser compatível com a amortização dos investimentos que serão realizados pelo parceiro privado.

Como as PPP's geralmente exigem grandes investimentos por parte do parceiro privado, é necessário um prazo longo para que ele possa compensar o valor investido.

- Limite de 35a: o prazo de 35 anos já inclui eventuais prorrogações, ou seja, a PPP jamais poderá ultrapassar 35 anos.

Lei Nacional n.º 11.079/2004

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever:

I – o prazo de vigência do contrato, compatível com a amortização dos investimentos realizados, não inferior a 5 (cinco), nem superior a 35 (trinta e cinco) anos, incluindo eventual prorrogação;

b) Valor mínimo de R\$ 10mi (art. 2º, § 4º, I, da Lei Nacional n.º 11.079/2004): para fazer uma Parceria Público-Privada, o valor mínimo deve ser de R\$ 10mi (dez milhões de reais).

Cuidado: na edição da Lei n.º 11.079/2004 esse valor era de R\$ 20mi; mas a Lei n.º 13.529/2017 reduziu para R\$ 10mi.

Lei Nacional n.º 11.079/2004

Art. 2º [...]

§ 4º É vedada a celebração de contrato de parceria público-privada:

I - cujo valor do contrato seja inferior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais);

c) Compartilhamento de riscos (art. 5º, III, da Lei Nacional n.º 11.079/2004): o contrato de PPP pode prever um compartilhamento de riscos entre os parceiros público e privado.

Ou seja, enquanto na concessão comum a permissionária ou concessionária presta o serviço público por sua conta e risco, aqui na PPP pode haver previsão de que o risco seja partilhado entre o Ente Federado delegante e o parceiro privado.

Esse compartilhamento de riscos deve estar expressamente previsto no contrato, podendo versar sobre:

- *Caso fortuito;*
- *Força maior;*
- *Fato do príncipe; e*
- *Álea econômica extraordinária.*

Lei Nacional n.º 11.079/2004

Art. 5º As cláusulas dos contratos de parceria público-privada atenderão ao disposto no art. 23 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, no que couber, devendo também prever:

III - a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária;

7. CONSÓRCIO PÚBLICO

Para finalizar, consórcio público é a gestão associada de Entes Federados (U+E+DF+M) visando melhor prestar os serviços públicos (art. 241, CRFB/1988).

Ex.: consórcio público entre a União e os estados da BA, PE e CE para levar água potável aos moradores do semiárido nordestino.

Constituição Federal

Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos.

~~1. Centralização~~

~~2. Descentralização~~

~~2.1. Descentralização por serviços ou outorga legal~~

~~2.2. Descentralização por colaboração ou delegação~~

~~2.2.1. Permissão~~

~~2.2.2. Concessão~~

~~2.2.2.1. Concessão comum~~

~~2.2.2.1.1. Concessão de serviço público~~

~~2.2.2.1.2. Concessão de serviço público precedida de obra~~

~~2.2.2.2. Parceria Público-privada (PPP)~~

~~2.2.2.2.1. Concessão patrocinada~~

~~2.2.2.2.2. Concessão administrativa~~

3. Consórcios Públicos

a) Protocolo de intenções: os Entes Federados que pretendem formar o consórcio público devem, antes, celebrar um protocolo de intenções.

Cada um dos Entes deve encaminhar esse protocolo de intenções, como um projeto de lei, ao respectivo Poder Legislativo para que este o ratifique.

- Anuência do Poder Legislativo: portanto, para que um Ente Federado (através do seu Poder Executivo) possa participar do consórcio público, ele deve ser autorizado pelo seu respectivo Poder Legislativo.

b) Formação do consórcio público: o consórcio público se forma com a ratificação legislativa do protocolo de intenções por meio da aprovação da lei (anuência do Poder Legislativo).

Portanto, assim como ocorre com as Autarquias, a formação do consórcio público decorre diretamente da lei: publicada a lei, está formado o consórcio público.

c) Personalidade jurídica pública ou privada: os Entes Federados que se consorciaram farão a opção pela constituição do consórcio com personalidade jurídica de direito público ou de

direito privado, conforme queiram, ou não, que o consórcio goze da prerrogativas de direito público.

- Associação civil: se os Entes que pretendem se consorciar quiserem constituir o consórcio com personalidade jurídica de direito privado, ou seja, sem as prerrogativas de direito público, deverão fazê-lo por meio de uma associação civil.

- Associação pública (autarquia): agora, se quiserem que o consórcio goze das prerrogativas de direito público, os Entes deverão constituir uma associação pública para formalizar o consórcio.

Ademais, a associação pública será uma Autarquia, que integrará a Administração indireta de cada um dos Entes Federados consorciados.

- Prerrogativas de direito público: mas quais são as prerrogativas do direito público? Abaixo, algumas delas:

- Prazo em dobro para as manifestações processuais (art. 183, CPC);
- Reexame necessário (art. 496, CPC);
- Intimação pessoal dos seus procuradores (art. 183, § 1º, CPC);
- Pagamentos dos débitos pelo regime dos precatórios (art. 100, CRFB/1988)
- ...

d) Nova pessoa jurídica: o consórcio público faz nascer uma nova PJ, que não se confunde com os Entes Federados (U+E+DF+M) consorciados.

Essa nova PJ terá patrimônio, bens, receita, administração... próprios.

e) Contrato de rateio: os Entes Federados consorciados devem formular um contrato de rateio, no qual definirão o valor do orçamento com que cada um participará do consórcio.

f) União X Município: por fim, a União e os municípios somente podem integrar um mesmo consórcio público se o Estado-membro, no qual se situa o respectivo município, também estiver participando.

8. QUESTÕES

01) () Serviço público é toda atividade exercida direta ou indiretamente pelo Poder Público com o escopo de prover necessidades essenciais do cidadão, da sociedade em geral e do próprio Poder Público.

02) () O princípio da regularidade informa que os serviços públicos não devem sofrer interrupções.

03) () Não fere a continuidade dos serviços públicos a sua descontinuidade em situações de emergência e, após aviso prévio aos usuários, por razões de ordem técnica, para a segurança das instalações ou por inadimplemento do usuário.

04) () Havendo inadimplemento, o serviço público sempre poderá ser interrompido, desde que o usuário seja previamente avisado.

05) () Os serviços públicos devem ser prestados sempre com a melhor tecnologia disponível.

06) () Segundo o princípio da generalidade ou universalidade, os serviços públicos devem ser prestados ao maior número possível de pessoas, mas o mesmo é limitado pelo princípio da reserva do possível.

07) () Serviços públicos *uti universi* são aqueles em que é possível identificar os usuários contemplados e mensurar o quantum que cada um utilizou, razão pela qual são remunerados por meio de impostos.

08) () Os serviços públicos remunerados por preços públicos ou taxas são os individuais.

09) () Na centralização dos serviços públicos, os mesmos são prestados diretamente pelo Ente Federado titular do mesmo.

10) () A descentralização ocorre quando um Ente federado passa para outro a prestação do serviço público.

11) () A execução do serviço público sempre é transferida quando ocorre sua descentralização, mas a titularidade somente é transferida nos casos de descentralização por serviços ou outorga legal.

12) () Os particulares, na descentralização por delegação ou colaboração, somente assumem a execução do serviço público, jamais sua titularidade.

13) () O instituto da permissão é um contrato administrativo de natureza precária.

14) () Na permissão e na concessão, os serviços públicos são repassados pelo Ente Federado para particulares, pessoas físicas ou jurídicas.

15) () Uma das grandes diferenças entre a permissão e a concessão de serviços públicos é que esta exige que o Poder Executivo obtenha autorização do respectivo Poder Legislativo para realizar a descentralização.

16) () Nas concessões comuns de serviço público, quem remunera o particular prestador do serviço é o próprio usuário.

- 17) ()** Quando o Poder Público também remunera a empresa concessionária, estar-se-á diante de parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada.
- 18) ()** Na concessão patrocinada, a contraprestação alcançada pelo Ente Federado nunca poderá superar 70% do custo do serviço público.
- 19) ()** O que qualifica uma parceria público-privada na modalidade concessão administrativa, é o fato de o serviço público ser prestado ao próprio Ente Federado contratante.
- 20) ()** O permissionário ou concessionário público é livre para transferir parcial ou totalmente a execução do serviço público ou o seu controle acionário.
- 21) ()** Acaso o particular permissionário ou concessionário de serviço público cause prejuízo a outrem, a responsabilidade do Ente Federado delegante é solidária.
- 22) ()** Dentre as prerrogativas do Ente Federado delegante, está a possibilidade de alterar unilateralmente o contrato, devendo o particular executante do serviço público aceitar a alteração, sem direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
- 23) ()** Verificando irregularidades na prestação do serviço público por parte do parceiro particular, o Poder Público deverá propor ação judicial para punir a falha.
- 24) ()** Para intervir junto ao particular, o Ente Federado deve expedir um decreto de intervenção, no qual deve exteriorizar os objetivos da medida, seus limites, o prazo da intervenção e quem será o interventor.
- 25) ()** Ao fim da intervenção, o Poder Público decretará a caducidade do contrato.
- 26) ()** O término do prazo contratual é a única forma extraordinária de extinção das permissões e concessões de serviços públicos.
- 27) ()** A encampação é a retomada do serviço público pelo Ente Federado quando houver interesse público, não cabendo qualquer direito ao parceiro particular.
- 28) ()** O que qualifica a caducidade como forma de extinção da permissão ou concessão de serviço público, é a inadimplência parcial ou total do particular.
- 29) ()** Com base na teoria da exceção do contrato não cumprido, o particular, permissionário ou concessionário, pode suspender a prestação do serviço público quando houver inadimplência do Ente Federado delegante.
- 30) ()** Com a extinção da permissão ou concessão, sob qualquer motivo, os bens reversíveis passarão à posse e propriedade do Ente Federado delegante, cabendo indenização ao particular se ainda não amortizados.
- 31) ()** Uma das grandes qualificações das parcerias público-privadas, é a possibilidade de prever que os riscos do negócio sejam compartilhados entre o parceiro privado e o Poder Público.

Q947724

Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXVII - Primeira Fase

A sociedade empresária Beta assinou, na década de 1990, contrato de concessão de serviço de transporte público. Desde então, vem utilizando os mesmos ônibus no transporte de passageiros, não se preocupando com a renovação da frota, tampouco com o conforto dos usuários ou com o nível de emissão de poluentes. Em paralelo, com a natural evolução

tecnológica, sabe-se que os veículos atualmente estão mais bem equipados, são mais seguros e, naturalmente, emitem menos poluentes.

Com base no caso narrado, assinale a afirmativa correta.

- () A) A renovação da frota visa a atender ao princípio da atualidade, que exige das concessionárias o emprego de equipamentos modernos.
- () B) Constitui interesse público a utilização de ônibus novos, mais econômicos, eficientes e confortáveis; por isso, independentemente de lei autorizativa, pode o poder concedente encampar o contrato de concessão, retomando o serviço público.
- () C) Se a concessionária desrespeitar os parâmetros de qualidade do serviço estabelecidos no contrato, a concessão poderá ser extinta unilateralmente pelo poder concedente, aplicando-se o instituto da rescisão.
- () D) Ao fim da concessão, os veículos utilizados retornam ao poder concedente, independentemente de expressa previsão no edital e no contrato.

Q369646

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2014 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XIII - Primeira Fase

O Estado X publicou edital de concorrência para a concessão de uma linha de transporte aquaviário interligando os municípios A e B, situados em seu território, por meio do Rio Azulão. Sobre o tema da concessão de serviços públicos, e considerando os dados acima narrados, assinale a afirmativa correta.

- () A) A outorga de concessão de serviço público, em regra, se dá em caráter de exclusividade.
- () B) O edital de licitação pode prever a utilização de receitas alternativas, provenientes da exploração de placas publicitárias, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas.
- () C) Não se admite a inserção, no contrato, de cláusula que preveja a arbitragem para a resolução de conflitos.
- () D) Na licitação para a concessão de serviços públicos, não se admite a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento.

Q542952

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VI - Primeira Fase - Reaplicação

São princípios próprios ou específicos dos serviços públicos, previstos na Lei 8.987/95:

- () A) moralidade, publicidade e legalidade.
- () B) especificidade, publicidade e moralidade.
- () C) continuidade, atualidade e cortesia.
- () D) atratividade, mutualismo e comutatividade.

Q156933

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2010 - OAB - Exame de Ordem Unificado - I - Primeira Fase

Júlia, que está desempregada, não conseguiu pagar a tarifa de energia elétrica de sua residência, referente ao mês de janeiro de 2010. Por esse motivo, o fornecimento de energia foi suspenso por ordem da diretoria da concessionária de energia elétrica, sociedade de economia mista.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção correta.

- () A) O fornecimento de energia elétrica à residência de Júlia não poderia ter sido suspenso em razão do inadimplemento, visto que, conforme entendimento do STJ, constitui serviço público essencial.
- () B) A lei de regência autoriza a suspensão do serviço desde que haja prévia notificação do usuário.
- () C) Lei estadual poderia, de forma constitucional, criar isenção dessa tarifa, nos casos de impossibilidade material de seu pagamento, como no caso do desemprego do usuário.
- () D) Não caberia mandado de segurança contra o ato da diretoria da concessionária, porque ela não é autoridade pública.

Q299411

Ano: 2007 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2007 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Acerca das definições contidas na Lei de Concessões Públicas (Lei n.º 8.987/1995), assinale a opção correta.

- () A) A concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante qualquer modalidade de licitação, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
- () B) O serviço público é adequado quando satisfizer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
- () C) A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, após a apresentação da proposta, mesmo quando não comprovado seu impacto, implica a revisão da tarifa, para mais ou para menos, conforme o caso.
- () D) Não será desclassificada, ab initio, a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.

Q304854

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - IX - Primeira Fase

Acerca dos serviços considerados como serviços públicos *uti singuli*, assinale a afirmativa correta.

- () A) Serviços em que não é possível identificar os usuários e, da mesma forma, não é possível a identificação da parcela do serviço utilizada por cada beneficiário.
- () B) Serviços singulares e essenciais prestados pela Administração Pública direta e indireta.
- () C) Serviços em que é possível a identificação do usuário e da parcela do serviço utilizada por cada beneficiário.
- () D) Serviços que somente são prestados pela Administração Pública direta do Estado.

Q318813

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2008 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

A campanha de prevenção à dengue desenvolvida em todo o território nacional pelo Ministério da Saúde, inclusive com a utilização dos populares fumacê, pode ser classificada como serviço público:

- () A) social autônomo.
- () B) *uti singuli*.
- () C) social vinculado.
- () D) *uti universi*.

Q733895

Ano: 2016 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2016 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXI - Primeira Fase

Uma autarquia federal divulgou edital de licitação para a concessão da exploração de uma rodovia que interliga diversos Estados da Federação. A exploração do serviço será precedida de obras de duplicação da rodovia. Como o fluxo esperado de veículos não é suficiente para garantir, por meio do pedágio, a amortização dos investimentos e a remuneração do concessionário, haverá, adicionalmente à cobrança do pedágio, contraprestação pecuniária por parte do Poder Público.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- () A) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa.
- () B) Trata-se de um consórcio público com personalidade de direito público entre a autarquia federal e a pessoa jurídica de direito privado.

- () C) Trata-se de um exemplo de parceria público-privada, na modalidade concessão patrocinada.
- () D) Trata-se de um exemplo de consórcio público com personalidade jurídica de direito privado.

Q304858

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - IX - Primeira Fase

Um estado da Federação, em processo de recuperação econômica, pretende restaurar o seu antigo Parque de Esportes, uma enorme área que concentra estádio de futebol, ginásio de esportes coletivos e parque aquático. Não dispondo de recursos para custear a totalidade da obra e nem tendo expertise para promover uma boa gestão do espaço, o Estado pretende firmar um contrato de parceria público-privada, nos moldes da Lei n. 11.079/2004.

Sobre o instituto da Parceria Público-Privada, assinale a afirmativa correta.

- () A) As parcerias público-privadas têm natureza de convênio, e não de contrato, uma vez que o ente público e o ente particular conjugam esforços na realização de uma atividade de interesse público.
- () B) As parcerias público-privadas preveem que o ente público executará uma parcela do serviço ou obra, nunca inferior a 50%, e o particular o restante do serviço ou obra.
- () C) As parcerias público-privadas não podem ter por objeto, exclusivamente, a execução de obra pública de restauração do Parque de Esportes.
- () D) As parcerias público-privadas remuneram o ente particular integralmente com o valor das tarifas cobradas dos usuários do serviço, sendo vedado ao ente público o custeio direto das atividades desenvolvidas pelo particular.

Q201160

Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2011 - OAB - Exame de Ordem Unificado - IV - Primeira Fase

O contrato de prestação de serviços de que a Administração Pública seja a usuária direta ou indireta, ainda que envolva a execução de obra ou fornecimento e instalação de bens, denomina-se concessão

- () A) comum.
- () B) patrocinada.
- () C) administrativa.
- () D) de uso de bem público.

Q205202

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB-SP Prova: CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

De acordo com a lei que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, assinale a opção incorreta.

- () A) Considera-se poder concedente a autarquia, fundação, empresa pública ou sociedade de economia mista em cuja competência se encontre o serviço público precedido, necessariamente, da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão.
- () B) Considera-se concessão de serviço público precedida da execução de obra pública a construção, total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado.
- () C) Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
- () D) Considera-se permissão de serviço público a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

Q1131574

Ano: 2020 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2020 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXXI - Primeira Fase

O Município Beta concedeu a execução do serviço público de veículos leves sobre trilhos e, ao verificar que a concessionária não estava cumprindo adequadamente as obrigações determinadas no respectivo contrato, considerou tomar as providências cabíveis para a regularização das atividades em favor dos usuários.

Nesse caso,

- () A) impõe-se a encampação, mediante a retomada do serviço pelo Município Beta, sem o pagamento de indenização.
- () B) a hipótese é de caducidade a ser declarada pelo Município Beta, mediante decreto, que independe da verificação prévia da inadimplência da concessionária.
- () C) cabe a revogação do contrato administrativo pelo Município Beta, diante da discricionariedade e precariedade da concessão, formalizada por mero ato administrativo.
- () D) é possível a intervenção do Município Beta na concessão, com o fim de assegurar a adequada prestação dos serviços, por decreto do poder concedente, que conterá designação do interventor, o prazo, os objetivos e os limites da medida.

Q973363

Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXVIII - Primeira Fase

O Governo do Estado Alfa, para impulsionar o potencial turístico de uma região cercada de belíssimas cachoeiras, pretende asfaltar uma pequena estrada que liga a cidade mais próxima ao local turístico. Com vistas à melhoria do serviço público e sem dinheiro em caixa para arcar com as despesas, o Estado decide publicar edital para a concessão da estrada, com fundamento na Lei nº 8.987/95, cabendo ao futuro concessionário a execução das obras.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- () A) O edital poderá prever, em favor da concessionária, outras fontes de receita além daquela oriunda do pedágio; a renda adicional deve favorecer a modicidade tarifária, reduzindo a tarifa paga pelos usuários.
- () B) Um grande investidor (pessoa física) pode ser contratado pelo poder concedente, caso demonstre capacidade de realização das obras.
- () C) A concessão pode ser feita mediante licitação na modalidade tomada de preços, caso as obras necessárias estejam orçadas em até R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).
- () D) O poder concedente não poderá exigir no edital garantias do concessionário de que realizará as obras a contento, dado que a essência do contrato de concessão é a delegação de serviço público.

Q881097

Ano: 2018 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2018 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXV - Primeira Fase

A União celebrou com a empresa Gama contrato de concessão de serviço público precedida de obra pública. O negócio jurídico tinha por objeto a exploração, incluindo a duplicação, de determinada rodovia federal. Algum tempo após o início do contrato, o poder concedente identificou a inexecução de diversas obrigações por parte da concessionária, o que motivou a notificação da contratada. Foi autuado processo administrativo, ao fim do qual o poder concedente concluiu estar prejudicada a prestação do serviço por culpa da contratada.

Com base na hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- () A) O contrato é nulo desde a origem, eis que a concessão de serviços públicos não pode ser precedida da execução de obras públicas.
- () B) O poder concedente pode declarar a caducidade do contrato de concessão, tendo em vista a inexecução parcial do negócio jurídico por parte da concessionária.
- () C) O poder concedente deve, necessariamente, aplicar todas as sanções contratuais antes de decidir pelo encerramento do contrato.

() D) O processo administrativo tem natureza de inquérito e visa coletar informações precisas dos fatos; por isso, não há necessidade de observar o contraditório e a ampla defesa da concessionária.

Q583039

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2015 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XVIII - Primeira Fase

Após dezenas de reclamações dos usuários do serviço de transporte metroviário, o Estado Y determinou a abertura de processo administrativo para verificar a prestação inadequada e ineficiente do serviço por parte da empresa concessionária.

Caso se demonstre a inadimplência, como deverá proceder o poder público concedente?

- () A) Declarar, por decreto, a caducidade da concessão.
- () B) Declarar, por decreto, a encampação do serviço.
- () C) Declarar, por decreto, após lei autorizativa, a revogação da concessão.
- () D) Declarar, por lei, a anulação do contrato de concessão.

Q490842

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2015 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XVI - Primeira Fase

Após fortes chuvas, devido ao enorme volume de água, parte de uma rodovia federal sofreu rachaduras e cedeu, tornando necessária a interdição da pista e o desvio do fluxo de tráfego até a conclusão das obras de reparo. A exploração da rodovia havia sido concedida, mediante licitação, à sociedade empresária "Traffega", e esta não foi capaz de lidar com a situação, razão pela qual foi decretada a intervenção na concessão.

Sobre a hipótese apresentada, assinale a afirmativa correta.

- () A) A intervenção somente pode ser decretada após a conclusão de processo administrativo em que seja assegurada a ampla defesa.
- () B) A administração do serviço será devolvida à concessionária, cessada a intervenção, se não for extinta a concessão.
- () C) A intervenção decorre da supremacia do interesse público sobre o privado e dispensa a instauração de processo administrativo.
- () D) A intervenção é causa obrigatória de extinção da concessão e assunção do serviço pelo poder concedente.

Q490839

Ano: 2015 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2015 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XVI - Primeira Fase

O Estado X, após regular processo licitatório, celebrou contrato de concessão de serviço público de transporte intermunicipal de passageiros, por ônibus regular, com a sociedade empresária "F", vencedora do certame, com prazo de 10 (dez) anos. Entretanto, apenas 5 (cinco) anos depois da assinatura do contrato, o Estado publicou edital de licitação para a concessão de serviço de transporte de passageiros, por ônibus do tipo executivo, para o mesmo trecho.

Diante do exposto, assinale a afirmativa correta.

- () A) A sociedade empresária "F" pode impedir a realização da nova licitação, uma vez que a lei atribui caráter de exclusividade à outorga da concessão de serviços públicos.
- () B) A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica ou econômica devidamente justificada.
- () C) A lei atribui caráter de exclusividade à concessão de serviços públicos, mas a violação ao comando legal somente confere à sociedade empresária "F" direito à indenização por perdas e danos.
- () D) A lei veda a atribuição do caráter de exclusividade à outorga de concessão, o que afasta qualquer pretensão por parte da concessionária, salvo o direito à rescisão unilateral do contrato pela concessionária, mediante notificação extrajudicial.

Q423509

Ano: 2014 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2014 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XIV - Primeira Fase

Caso o Estado delegue a reforma, manutenção e operação de uma rodovia estadual à iniciativa privada, com a previsão de que a amortização dos investimentos e a remuneração do particular decorram apenas da tarifa cobrada dos usuários do serviço, estaremos diante de uma:

- () A) concessão de obra pública.
- () B) concessão administrativa.
- () C) concessão patrocinada.
- () D) concessão de serviço público precedida da execução de obra pública.

Q304935

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VIII - Primeira Fase

Uma concessionária de serviço público, em virtude de sua completa inadequação na prestação do serviço, não consegue executar o contrato.

Nesse caso, segundo a Lei n. 8.987/95, poderá ser declarada, a critério do poder concedente, a extinção do contrato por

- () A) caducidade.
- () B) encampação
- () C) anulação.
- () D) revogação.

Q201161

Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2011 - OAB - Exame de Ordem Unificado - IV - Primeira Fase

Ao tomar conhecimento de que o serviço público de transporte aquaviário concedido estava sendo prestado de forma inadequada, causando gravíssimos transtornos aos usuários, o ente público, na qualidade de poder concedente, instaurou regular processo administrativo de verificação da inadimplência da concessionária, assegurando-lhe o contraditório e a ampla defesa. Ao final do processo administrativo, restou efetivamente comprovada a inadimplência, e o poder concedente deseja extinguir a concessão por inexecução contratual. Qual é a modalidade de extinção da concessão a ser observada no caso narrado?

- () A) Encampação.
- () B) Caducidade.
- () C) Rescisão.
- () D) Anulação.

Q155407

Ano: 2011 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2011 - OAB - Exame de Ordem Unificado - III - Primeira Fase

O prefeito de um determinado município resolve, por decreto municipal, alterar unilateralmente as vias de transporte de ônibus municipais, modificando o que estava previsto nos contratos de concessão pública de transportes municipais válidos por vinte anos. O objetivo do prefeito foi favorecer duas empresas concessionárias específicas, com que mantém ligações políticas e familiares, ao lhes conceder os trajetos e linhas mais rentáveis. As demais três empresas concessionárias que também exploram os serviços de transporte de ônibus no município por meio de contratos de concessão sentem-se prejudicadas.

Na qualidade de advogado dessas últimas três empresas, qual deve ser a providência tomada?

- () A) Ingressar com ação judicial, com pedido de liminar para que o Poder Judiciário exerça o controle do ato administrativo expedido pelo prefeito e decrete a sua nulidade ou suspensão imediata, já que eivado de vício e nulidade, por configurar ato fraudulento e atentatório aos princípios que regem a Administração Pública.

- () B) Ingressar com ação judicial, com pedido de indenização em face do Município pelos prejuízos de ordem financeira causados.
- () C) Nenhuma medida merece ser tomada na hipótese, tendo em vista que um dos poderes conferidos à Administração Pública nos contratos de concessão é a modificação unilateral das suas cláusulas.
- () D) Ingressar com ação judicial, com pedido para que os benefícios concedidos às duas primeiras empresas também sejam extensivos às três empresas clientes.

Q171056

Ano: 2010 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2010 - OAB - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Assinale a opção correta de acordo com a Lei n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos.

- () A) Considera-se concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
- () B) A concessão de serviço público que não for precedida da execução de obra pública poderá ser formalizada mediante acordo verbal.
- () C) A permissão de serviço público ocorre mediante título precário e sem licitação.
- () D) As concessões e permissões estão sujeitas à fiscalização pelo poder concedente responsável pela delegação, independentemente da cooperação dos usuários.

Q129223

Ano: 2010 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2010 - OAB - Exame de Ordem Unificado - II - Primeira Fase

Uma determinada empresa concessionária transfere o seu controle acionário para uma outra empresa privada, sem notificar, previamente, o Poder concedente, parte no contrato de concessão.

Assinale a alternativa que indique a medida que o Poder concedente poderá tomar, se não restarem atendidas as mesmas exigências técnicas, de idoneidade financeira e regularidade jurídica por esta nova empresa.

- () A) Poderá o Poder concedente declarar a caducidade da concessão, tendo em vista o caráter *intuitu personae* do contrato de concessão.
- () B) Poderá retomar o serviço, por motivo de interesse público, através da encampação, autorizada por lei específica, após prévio pagamento da indenização.
- () C) Poderá o Poder concedente anular o contrato de concessão, através de decisão administrativa, uma vez que a transferência acionária da empresa concessionária sem a notificação prévia ao Poder concedente gera irregularidade, insusceptível de convalidação.
- () D) Nada poderá fazer o Poder concedente, uma vez que a empresa concessionária, apesar da alteração societária, não desnatura o caráter *intuitu personae* do contrato de concessão.

Q171777

Ano: 2009 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2009 - OAB - Exame de Ordem - 1 - Primeira Fase

Conforme dispõe a lei geral de concessões, a encampação consiste:

- () A) no retorno dos bens públicos aplicados na execução do objeto do contrato de concessão ao poder concedente.
- () B) na declaração de extinção do contrato de concessão em face da inexecução total ou parcial do contrato, desde que respeitados o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.
- () C) na retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização.
- () D) no fim do contrato de concessão, por iniciativa do concessionário, quando houver descumprimento das condições do contrato pelo poder concedente.

Q171335

Ano: 2009 Banca: CESPE Órgão: OAB Prova: CESPE - 2009 - OAB - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Considere que, após o devido processo licitatório, a administração pública tenha delegado a execução de um serviço público a um particular para que este executasse o serviço em seu próprio nome, por sua conta e risco, pelo prazo de cinco anos. Em troca, conforme previsão contratual, o particular receberia, a título de remuneração, a tarifa paga pelos usuários do serviço.

Nesse caso, a administração pública firmou contrato de

- () A) concessão de serviço público.
- () B) permissão de serviço público.
- () C) autorização de serviço público.
- () D) empreitada de serviço público.

Q205065

Ano: 2008 Banca: CESPE Órgão: OAB-SP Prova: CESPE - 2008 - OAB-SP - Exame de Ordem - 3 - Primeira Fase

Acerca do regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da CF e regulado pela Lei n.º 8.987/1995, assinale a opção correta.

- () A) A subconcessão dos serviços pela concessionária contratada pelo poder concedente é de livre pactuação.
- () B) A transferência do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente não atinge o contrato de concessão.
- () C) Os contratos relativos à concessão de serviço público precedido da execução de obra pública deverão, adicionalmente aos demais requisitos previstos para os outros tipos de concessão, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão.
- () D) O contrato de concessão, por constituir contrato administrativo, não pode submeter-se ao emprego de mecanismos privados para resolução de disputas, como, por exemplo, a arbitragem.

Q207866

Ano: 2007 Banca: VUNESP Órgão: OAB-SP Prova: VUNESP - 2007 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Sobre os contratos de concessão de serviços, é incorreto afirmar que

- () A) têm como espécies a concessão comum, a concessão patrocinada e a concessão administrativa.
- () B) são necessariamente precedidos de licitação na modalidade de concorrência.
- () C) são sujeitos à intervenção do Poder Concedente.
- () D) são encampáveis pelo Poder Concedente independentemente de autorização legislativa, mas mediante prévia indenização.

Q208166

Ano: 2005 Banca: OAB-SP Órgão: OAB-SP Prova: OAB-SP - 2005 - OAB-SP - Exame de Ordem - 2 - Primeira Fase

Qual a forma de extinção de um contrato de concessão celebrado entre um município e uma sociedade de economia mista estadual, que, para sua efetivação, necessite, obrigatoriamente, de lei autorizativa específica e prévio pagamento de indenização?

- () A) Encampação.
- () B) Caducidade.
- () C) Intervenção.
- () D) Rescisão contratual.

Q1003647

Ano: 2019 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2019 - OAB - Exame de Ordem Unificado XXIX - Primeira Fase

O Município Alfa planeja estabelecer uma parceria público-privada para a construção e operação do metrô, cujo contrato terá vigência de trinta e cinco anos. Como a receita com a venda das passagens é inferior ao custo de implantação/operação do serviço, o ente local aportará recursos como complementação da remuneração do parceiro privado.

Sobre a questão, assinale a afirmativa correta.

- () A) Como o parceiro privado será remunerado pela tarifa do serviço de transporte e por uma contrapartida do poder público, a concessão será celebrada na modalidade administrativa.
- () B) A contrapartida do parceiro público somente pode se dar em dinheiro, não sendo permitido qualquer outro mecanismo, a exemplo da outorga de direitos em face da Administração Pública.
- () C) A vigência do futuro contrato é adequada, mas, por se tratar de negócio com duração de trinta e cinco anos, não poderá haver prorrogação contratual.
- () D) Independentemente da proporção da contrapartida do parceiro público frente ao total da receita auferida pelo parceiro privado, não haverá necessidade de autorização legislativa específica.

Q852384

Ano: 2017 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2017 - OAB - Exame de Ordem Unificado - XXIV - Primeira Fase

Um Estado da Federação lançou um grande programa de concessões como forma de fomentar investimentos, diante das dificuldades financeiras por que vem passando. Por meio desse programa, ele pretende executar obras de interesse da população e ceder espaços públicos para a gestão da iniciativa privada. Como parte desse programa, lançou edital para restaurar um complexo esportivo com estádio de futebol, ginásio de esportes, parque aquático e quadras poliesportivas.

Diante da situação acima, assinale a afirmativa correta.

- () A) O Estado pode optar por celebrar uma parceria público-privada na modalidade de concessão patrocinada, desde que o contrato tenha valor igual ou superior a R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) e que as receitas decorrentes da exploração dos serviços não sejam suficientes para remunerar o particular.
- () B) A constituição de sociedade de propósito específico - SPE, sociedade empresária dotada de personalidade jurídica e incumbida de implantar e gerir o objeto da parceria, deve ocorrer após a celebração de um contrato de PPP.
- () C) O contrato deverá prever o pagamento de remuneração fixa vinculada ao desempenho do parceiro privado, segundo metas e padrões de qualidade e disponibilidade nele definidos.
- () D) A contraprestação do Estado deverá ser obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço que é objeto do contrato de parceria público-privada; dessa forma, não é possível o pagamento de contraprestação relativa à parcela fruível do serviço contratado.

Q542956

Ano: 2012 Banca: FGV Órgão: OAB Prova: FGV - 2012 - OAB - Exame de Ordem Unificado - VI - Primeira Fase - Reaplicação

Em determinado contrato de concessão de serviços públicos patrocinada, foi acordado entre as partes que o poder concedente assumiria os riscos decorrentes de fato do príncipe e o concessionário aqueles que decorressem de caso fortuito ou força maior.

De acordo com a legislação acerca da matéria, é possível afirmar que tal estipulação contratual é:

- () A) nula, pois o contrato não pode atribuir ao concessionário a responsabilidade por fatos imprevisíveis, cujos efeitos não era possível evitar ou prever. Assim, não havendo culpa, não é possível a atribuição, por contrato, de tal responsabilidade.
- () B) nula, pois em toda e qualquer concessão de serviço público, todos os riscos inerentes ao negócio são de responsabilidade do concessionário. Assim, a atribuição de responsabilidade ao concedente pelos riscos decorrentes de fato do príncipe viola a legislação acerca da matéria.
- () C) válida, pois a lei de parcerias público-privadas atribui ao contrato autonomia para definir a repartição de riscos entre as partes, inclusive os referentes a caso fortuito, força maior, fato do príncipe e álea econômica extraordinária.

() D) válida, pois inerente ao princípio da autonomia contratual, que apenas veicula hipótese de repartição objetiva de riscos entre o Poder Público e o concessionário e que se encontra previsto na legislação pátria desde o advento da Lei 8.666/93.

LICITAÇÕES

1. INTRODUÇÃO e CONCEITO

- 1.1. Mandamento Constitucional
- 1.2. Leis Existentes
- 1.3. Para que Serve uma Licitação?
- 1.4. Conceito de Licitação
- 1.5. Objeto da Licitação

2. PRINCÍPIOS

- 2.1. Legalidade
- 2.2. Impessoalidade e Interesse Público
- 2.3. Moralidade e Probidade Administrativa
- 2.4. Igualdade e Competitividade
- 2.5. Publicidade, Transparência e Sigilo das Propostas
- 2.6. Eficiência, Eficácia e Economicidade
- 2.7. Planejamento
- 2.8. Segregação de Funções
- 2.9. Motivação
- 2.10. Vinculação ao Edital
- 2.11. Julgamento Objetivo
- 2.12. Segurança Jurídica
- 2.13. Razoabilidade e Proporcionalidade
- 2.14. Celeridade
- 2.15. Desenvolvimento Nacional Sustentável
- 2.16. Princípios Implícitos ou Correlatos

3. OBJETIVOS DA LICITAÇÃO

4. AGENTES PÚBLICOS DA LICITAÇÃO

- 4.1. Agentes Públicos
- 4.2. Agente de Contratação
- 4.3. Assistência Jurídica para Autoridade e Agentes Públicos

5. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- 5.1. Noções Gerais
- 5.2. Concorrência
- 5.3. Pregão
- 5.4. Concurso
- 5.5. Leilão
- 5.6. Diálogo Competitivo

6. CRITÉRIOS DE JULGAMENTO

- 6.1. Menor Preço e Maior Desconto
- 6.2. Melhor Técnica ou Conteúdo Artístico
- 6.3. Técnica e Preço
- 6.4. Maior Retorno Econômico
- 6.5. Maior Lance

1. INTRODUÇÃO e CONCEITO

1.1. Mandamento Constitucional

A necessidade de realizar licitação decorre diretamente da Constituição Federal.

a) Obras, serviços, compras e alienações (art. 37, XXI, CRFB/1988): a Constituição Federal 988 determina que as obras, serviços, compras e alienações da Administração pública serão contratados mediante processo de licitação pública.

b) Adm. direta e indireta: a licitação se aplica à toda a Administração pública brasileira:

- Administração direta: U+E+DF+M (Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário dos Entes federados).
- Administração indireta: A+FP+EP+SEM (entidades administrativas do Poder Executivo)

c) Competência Legislativa: todos os Entes federados brasileiros podem legislar sobre licitações, mas atendidas as condições que seguem.

- União = normas gerais (art. 22, XXVII): a União possui competência legislativa privativa para criar leis dispondo sobre as regras gerais das licitações; essas regras gerais aplicar-se-ão a todos os Entes federados (U+E+DF+M).

A União fará isso através do seu Poder Legislativo: Congresso Nacional (Senado Federal + Câmara dos Deputados).

- E+DF+M = regras específicas: os estados, o Distrito Federal e os municípios possuem competência legislativa para editarem normas específicas.

Farão isso também através do seu respectivo Poder Legislativo: Assembleia Legislativa (estados), Câmara Legislativa (DF) e Câmara de Vereadores (municípios).

- Normas gerais X específicas: não há uma definição muito precisa do que sejam normas gerais e normas específicas; mas há consenso de que são normas gerais aquelas que digam respeito ao seguinte – sobre estas situações, portanto, somente a União poderá legislar:

- *Modalidades de licitação;*
- *Critérios de julgamento;*
- *Condições de habilitação;*
- *Casos em que se admite contratação direta (sem licitação).*

CRFB/1988

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:

XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1º, III;

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

Art. 173. [...]

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

III - licitação e contratação de obras, serviços, compras e alienações, observados os princípios da administração pública;

1.2. Leis Existentes

Atualmente, as leis que tratam sobre licitações e contratos administrativos são as que seguem.

a) U+E+DF+M e A+FP: para os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário dos Entes federados (Administração direta) e para as autarquias e fundações públicas dos Poderes Executivos (Administração indireta) dos Entes federados, aplicam-se as seguintes leis:

- *Lei Nacional n.º 8.666/1993*;

- *Lei Nacional n.º 10.520/2002*;

- *Lei Nacional n.º 12.462/2011*;

- *Lei Nacional n.º 14.133/2021*: esta lei substituiu as acima, mas não de forma imediata. Durante o período de dois anos, a Administração poderá optar por licitar e contratar com base nesta nova lei ou nas anteriores; trata-se de um período de transição que permitirá que os agentes públicos se familiarizem com a nova Lei de Licitações e Contratos. Mas é vedada a combinação da legislação antiga com a nova, ou seja, a Administração pública deve optar por utilizar totalmente as regras das leis antigas ou totalmente as regras desta nova lei.

b) EP+SEM (art. 173, § 1º, III, CRFB/1988): para as empresas estatais (empresas públicas e sociedades de economia mista) dos Poderes Executivos (Administração indireta), a Constituição Federal prevê que a lei estabelecerá o seu estatuto jurídico, o qual deverá dispor sobre licitação e contratação de obras+serviços+compras+alienações.

- *Lei Nacional n.º 13.303/2016*: essa é a lei que trata do assunto.

→ FP de direito público e privado: relembre-se que as fundações públicas podem ser de direito público ou privado. O cuidado que se deve ter é que a Lei Nacional n.º 14.133/2021 aplica-se a ambas (e não apenas para as de direito público).

- Fundação pública de direito público: também chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional, goza dos privilégios da fazenda pública;
- Fundação pública de direito privado: é a fundação pública que não goza dos privilégios da fazenda pública;
- Fundação privada (esta sempre é de direito privado): esta não interessa ao nosso estudo, submetendo-se às regras do Código Civil. Ex.: Fundação Xuxa Meneghel e Fundação Airton Senna.

1.3. Para que Serve uma Licitação?

Uma licitação serve para escolher com quem a Administração pública irá contratar, estando, por isso, sempre ligada a um contrato administrativo posterior.

a) Licitação = escolha: um exemplo ajuda a entender. Imagine-se que a Prefeitura deseja construir uma creche; ela pode fazer isso diretamente, através dos seus servidores públicos, ou pode contratar essa obra com terceiros. Se quiser contratar um terceiro para construir a creche, a Administração não pode (princípio da impessoalidade) simplesmente escolher alguém no mercado; ela deve fazer um processo de licitação, no qual todos que preencham os requisitos exigidos (princípio da igualdade) poderão participar, sendo escolhido aquele que oferecer a proposta mais vantajosa para o Poder Público.

Portanto, percebe-se que a licitação destina-se a escolher com quem a Administração contratará essa obra de construção da creche.

É a mesma situação que ocorre em um concurso público: o concurso público é a forma de a Administração pública escolher quem trabalhará para ela, sendo que todos que preenchem os requisitos do concurso podem participar.

b) Contrato Administrativo = contratação: uma vez escolhido (licitação) o terceiro que realizará a construção da creche, a Administração e esse terceiro assinarão um contrato administrativo.

Quando nós, particulares, contratamos alguém para construir uma casa, por exemplo, também formalizamos esse negócio através de um contrato, no qual constará o valor, prazo, forma de execução, obrigações, direitos, deveres... Com a Administração pública não é diferente: uma vez que ela escolheu com quem contratar (licitação), as partes deverão formalizar a situação através da assinatura de um contrato (contrato administrativo).

No caso do concurso público, uma vez escolhidas as pessoas (lista de classificação), a Administração chamará (nomeação) o candidato para dizer se aceita (tomar posse) trabalhar para ela (entrar em exercício) – na iniciativa privada, essa contratação ocorre por meio da assinatura da CTPS; no serviço público, por meio dos atos formais de posse e exercício.

1.4. Conceito de Licitação

A doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro define licitação da seguinte forma:

[...] pode-se definir a licitação como o procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício da função administrativa, abre a todos os interessados, que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório, a possibilidade de formularem propostas dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração de contrato.

1.5. Objeto da Licitação

Conforme já mencionado, será realizada licitação para obras, serviços, compras e alienações (art. 37, XXI, CRFB/1988); todavia, temos algumas leis específicas que tratam de situações peculiares.

a) Lei Nacional n.º 14.133/2021: conforme seu art. 2º, aplica-se para:

- Alienação e concessão de direito real de uso de bens;
- Compra, inclusive por encomenda;
- Locação, em que a Administração seja a locadora;
- Concessão e permissão de uso de bens públicos.
- Prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
- Obras e serviços de arquitetura e engenharia;
- Contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

→ Exceções: a Lei Nacional n.º 14.133/2021 não se aplica para (art. 3º):

- Operação de crédito e gestão da dívida pública: como exemplo, quando a União desejar realizar um financiamento (operação de crédito) ou quando refinarciar um empréstimo já realizado (gestão da dívida pública).
- Contratações com legislação própria: como exemplo, quando um município quiser alugar um bem privado para instalar um órgão público (a Administração será a inquilina, locatária), aplica-se a Lei de Locações (n.º 8.245/1991).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 2º Esta Lei aplica-se a:

- I - alienação e concessão de direito real de uso de bens;
- II - compra, inclusive por encomenda;
- III - locação;
- IV - concessão e permissão de uso de bens públicos;
- V - prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados;
- VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia;
- VII - contratações de tecnologia da informação e de comunicação.

Art. 3º Não se subordinam ao regime desta Lei:

- I - contratos que tenham por objeto operação de crédito, interno ou externo, e gestão de dívida pública, incluídas as contratações de agente financeiro e a concessão de garantia relacionadas a esses contratos;
- II - contratações sujeitas a normas previstas em legislação própria.

Lei Nacional n.º 8.245/1991

Dispõe sobre as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes.

b) Lei Nacional n.º 8.987/1995: aplica-se para:

- *Concessão e permissão de serviços públicos* (mas devem ser observadas, de forma subsidiária, as disposições da Lei Nacional n.º 14.133/2021).

Lei Nacional n.º 8.987/1995

Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências.

c) Lei Nacional n.º 11.079/2004: aplica-se para:

- *Parcerias Público-Privadas (PPPs)* (mas devem ser observadas, de forma subsidiária, as disposições da Lei Nacional n.º 14.133/2021).

Lei Nacional n.º 11.079/2004

Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública.

d) Lei Nacional n.º 12.232/2020: aplica-se para:

- *Serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda* (mas devem ser observadas, de forma subsidiária, as disposições da Lei Nacional n.º 14.133/2021).

Lei Nacional n.º 12.232/2020

Dispõe sobre as normas gerais para licitação e contratação pela administração pública de serviços de publicidade prestados por intermédio de agências de propaganda e dá outras providências.

→ Concessão e permissão: cuidado com a concessão e a permissão – não se deve confundir a concessão e permissão de serviços públicos com a concessão e permissão para uso de bens públicos, nem com a concessão de direito real de uso de bens públicos.

- *Concessão de direito real de uso de bens* (incide a Lei Nacional n.º 14.133/2021): como exemplo, uma licitação para a escolha de famílias que ocuparão residências populares de propriedade do município.

- *Concessão e permissão de uso de bens públicos* (incide a Lei Nacional n.º 14.133/2021): como exemplo, a Administração pública poderá lançar um processo de licitação para a concessão de uso de um quiosque de praia – trata-se de um bem público que será usado por um particular para vender seus produtos.

- *Concessão e permissão de serviços públicos* (incide a Lei Nacional n.º 8.987/1995): como exemplo, o lançamento de uma licitação para a escolha da empresa que explorará o serviço público de transporte urbano de passageiros de algum município.

2. PRINCÍPIOS

→ Mnemônico: o art. 5º da Lei de Licitações traz, expressamente, muitos princípios.

"JoVeM, SEMPRE LICITE Com Planejamento Pro País Desenvolver Sustentavelmente."

- Julgamento objetivo;
- Vinculação ao edital;
- Motivação;
- Segregação de funções;
- Economicidade;
- Moralidade;
- Publicidade;
- Razoabilidade;
- Eficiência;
- Legalidade;
- Impessoalidade;
- Celeridade;
- Igualdade;
- Transparência;
- Eficácia;
- Competitividade;
- Planejamento;
- Proportionalidade;
- Probidade administrativa;
- Interesse público;
- Segurança jurídica;
- Desenvolvimento nacional sustentável.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

2.1. Legalidade

a) Regras definidas em lei: o princípio da legalidade significa que a Administração pública deverá seguir as regras definidas em lei – ao agente público, somente é lícito fazer o que a lei autoriza ou determina.

b) Devido processo legal: especificamente em relação às licitações, o princípio da legalidade significa também que a licitação deverá seguir o devido processo legal, eis que o rito da licitação é definido em lei, devendo ocorrer segundo a modalidade de licitação prevista para o caso.

Exige também que a Administração apenas dispense o procedimento licitatório – ou seja, não realize licitação – nos casos especificados em lei (estudaremos dispensa de licitação adiante).

c) Ato administrativo formal: o procedimento licitatório é um ato administrativo formal, de modo que todos aqueles que participam da licitação têm o direito público subjetivo à fiel observância das regras previstas na Lei de Licitações.

Contudo, o formalismo não pode ser exagerado, por isso é comum se falar em formalismo moderado, conforme estudaremos.

2.2. Impessoalidade e Interesse Público

a) Impessoalidade + interesse Público = finalidade: o princípio da impessoalidade consta expressamente no *caput* do art. 37 da CRFB/1988 e representa a ideia de que toda a atuação da Administração pública deve buscar atender ao interesse público (também denominado princípio da finalidade) – logo, podemos dizer que impessoalidade e interesse público são princípios interligados ou até mesmo sinônimos.

Também se relacionam ao princípio da impessoalidade e do interesse público muitos outros princípios, como a igualdade e o julgamento objetivo, uma vez que exigem que a Administração trate os licitantes em igualdade de condições, analisando as propostas a partir de critérios objetivos previamente definidos, sem privilegiar alguém por critérios meramente pessoais e desconexos com o interesse público.

2.3. Moralidade e Probidade Administrativa

a) Mais que legalidade: os princípios da moralidade e da probidade administrativa possuem uma relação muito íntima, ao ponto de alguns autores afirmarem que são sinônimos.

Ambos significam que o comportamento da Administração pública não deve ser apenas lícito, mas também baseado na moral, nos bons costumes, nas regras de boa administração, nos princípios da justiça e equidade, na ideia comum de honestidade.

Também há uma proximidade muito grande da moralidade com a impessoalidade, uma vez que o agente público que age de forma pessoal em uma licitação, favorecendo amigos ou parceiros políticos, atentar-se-á tanto contra a impessoalidade como contra a moralidade.

b) Programa de integridade (+200mi) (art. 25, § 4º): para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto – valor superior a 200 milhões –, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de seis meses, contado da celebração do contrato.

Como são contratos relevantes (de grande vulto), a implementação de um programa de integridade poderá corroborar para promoção da moralidade na entidade contratada.

c) Vedação ao nepotismo (art. 48, único): outra disposição relevante sobre a moralidade, probidade e impessoalidade é a ampliação do alcance da vedação ao nepotismo – nos contratos de terceirização, o contratado fica proibido de contratar parente (até terceiro grau)

de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 25. [...]

§ 4º Nas contratações de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto, o edital deverá prever a obrigatoriedade de implantação de programa de integridade pelo licitante vencedor, no prazo de 6 (seis) meses, contado da celebração do contrato, conforme regulamento que disporá sobre as medidas a serem adotadas, a forma de comprovação e as penalidades pelo seu descumprimento.

Art. 48. [...]

Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do órgão ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação.

2.4. Igualdade e Competitividade

a) Igualdade ou isonomia = sem favorecimentos: a licitação deverá ser realizada sem favorecimentos, discriminações ou exigências indevidas, pois deve ser permitido que os licitantes concorram em igualdade de condições.

É por isso que a Constituição Federal determina que as contratações serão precedidas de "[...] processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, [...] o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações" (art. 37, XXI, CRFB/1988).

b) Competitividade = sem restrições indevidas: somente serão legítimas as exigências imprescindíveis para assegurar a execução do objeto da licitação, para não comprometer a ampla competitividade.

Há relação direta entre a igualdade e a competitividade: ao assegurar um processo isonômico, sem restrições indevidas, a Administração pública também permitirá a participação de um maior número de concorrentes.

Com exemplo, em um contrato de maior complexidade seria legítimo exigir dos licitantes alguns comprovantes de participação em outros projetos com características semelhantes, desde que essa exigência seja imprescindível para assegurar a correta execução do objeto da licitação. Mas essa exigência não é necessária em situações corriqueiras e de baixa complexidade.

A própria Lei de Licitações já traz algumas previsões específicas que buscam assegurar o cumprimento dos princípios da isonomia e da competitividade. Por exemplo: em regra, não se admite a indicação de marca ou de modelo, exceto em casos excepcionais devidamente justificados (art. 41, I). Do mesmo modo, mas em sentido inverso, via de regra não se admite a vedação a uma marca ou produto específico, salvo se ficar comprovado, em processo administrativo, que um produto adquirido anteriormente não atendeu a requisitos indispensáveis para cumprir o contrato.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

- a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
- b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;
- c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;
- d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

II - [...]

c) Vedação à restrição do caráter competitivo (art. 9º): é vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, bem como a terceiro que auxilie na condução dos trabalhos:

- *Comprometer o caráter competitivo da licitação;*
- *Estabelecer distinções em razão da naturalidade, sede ou domicílio dos licitantes;*
- *Exigir requisitos impertinentes ou irrelevantes para o objeto do contrato;*
- *Estabelecer tratamento diferenciado entre empresas brasileiras e estrangeiras;*
- *Opor resistência injustificada ao andamento dos processos;*
- *Deixar de praticar ato de ofício;*
- *Praticar ato de ofício contra a lei;*
- *Participar da licitação ou da execução do contrato.*

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

- a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;
- b) estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou do domicílio dos licitantes;
- c) sejam impertinentes ou irrelevantes para o objeto específico do contrato;

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, modalidade e local de pagamento, mesmo quando envolvido financiamento de agência internacional;

III - opor resistência injustificada ao andamento dos processos e, indevidamente, retardar ou deixar de praticar ato de ofício, ou praticá-lo contra disposição expressa em lei.

§ 1º Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato agente público de órgão ou entidade licitante ou contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria.

§ 2º As vedações de que trata este artigo estendem-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

d) Vedação à participação do autor do projeto (art. 14): aqueles que participaram da elaboração do projeto daquilo que será licitado e depois contratado, logicamente não podem participar da licitação, pois teriam uma vantagem sobre os demais, ferindo os princípios da igualdade e competitividade.

Nessa linha, não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato:

- *Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo;*
- *Empresa responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo;*
- *Exceções:*
 - *Atividades de apoio (art. 14, § 2º):* os autores dos projetos podem, a critério da Administração pública, apoiar as atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, mas sempre sob supervisão de agentes públicos do órgão ou entidade;
 - *Contratação integrada (art. 14, § 4º):* quando a própria licitação inclui como encargo do contratado a elaboração dos projetos básico e executivo – aqui o contratado terá de elaborar os projetos e executar o serviço.

Mas o art. 14 da Lei de Licitações também traz outras vedações de participação na licitação, quais sejam (não podem participar da licitação nem executar o contrato):

- *Empresas controladoras, controladas ou coligadas (grupo econômico);*
- *Quem mantém vínculo com dirigente do órgão ou entidade (ou parente até 3º grau);*
- *Quem mantém vínculo com agente público que atua na licitação, fiscalização ou gestão do contrato (ou parente até 3º grau);*
- *PF ou PJ impossibilitada de licitar por sanção;*
- *PF ou PJ condenada (trânsito em julgado) por exploração de trabalho infantil, submissão a condições análogas à escravidão ou por contratação de adolescentes nos casos vedados;*
- *Empresa que atua em substituição a outra (art. 14, § 1º).*

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 14. Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato, direta ou indiretamente:

I - autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

II - empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

III - pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

IV - aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação;

V - empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

VI - pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

§ 1º O impedimento de que trata o inciso III do caput deste artigo será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

§ 2º A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os incisos I e II do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de

gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

§ 3º Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

§ 4º O disposto neste artigo não impede a licitação ou a contratação de obra ou serviço que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.

§ 5º Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidônea nos termos desta Lei.

e) Flexibilizações ou exceções: há uma série de flexibilizações ou exceções aos princípios da isonomia, igualdade e competitividade – em que pese a igualdade seja a regra, ela será flexibilizada ou excepcionada em casos específicos.

A lista a seguir não é exaustiva, mas serve para mencionar alguns casos em que a própria legislação cria preferências ou restrições à competitividade no âmbito das licitações.

- Critério de desempate e critério de preferência (art. 60): em caso de empate entre duas ou mais propostas, a Lei de Licitações estabelece os critérios de desempate; caso o empate persista, serão aplicados os critérios de preferência.

- Critérios de desempate: (i) disputa final entre os empatados; (ii) avaliação de desempenho contratual prévio; (iii) ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho; e (iv) programa de integridade.

- Critérios de preferência: (i) empresa estabelecida no território do Estado ou DF; (ii) empresa brasileira; (iii) empresas que investe em pesquisa e tecnologia no País; e (iv) empresas que comprovem a prática de mitigação de emissão de gases e consumo de matéria prima (Lei Nacional n.º 12.187/2009).

- Margem de preferência (art. 26): a margem de preferência permite que a Administração pública contrate um licitante com oferta um pouco mais cara do que a proposta de outro licitante.

Para entender melhor: imagine que você vai comprar um computador e faz orçamento em uma grande rede do varejo e na loja do seu bairro, sendo que o orçamento da grande loja ficou um pouco mais barato do que o da loja do seu bairro; apesar disso, você opta por comprar na loja do seu bairro para fomentar a economia local.

A margem de preferência é algo semelhante: aqui a Administração pública vai pagar um pouco mais caro por questões ligadas a desenvolvimento, geração de emprego e renda... A lógica é a seguinte: às vezes, é melhor pagar um pouco mais caro em um produto fabricado no país do que em um importado.

- Até 10%: quando se tratar de (i) bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras e (ii) bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, a Administração pode pagar até 10% a mais.

- Até 20%: quando se tratar de bens manufaturados e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, a Administração pública pode pagar até 20% a mais.

- Medidas de compensação (art. 26, § 6º): os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão exigir que o contratado promova medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento.

Exemplo: numa licitação internacional envolvendo grandes valores, para a aquisição de algum produto de tecnologia, o edital poderá exigir medidas de compensação ao vencedor, como o compartilhamento de tecnologias com a Administração pública.

- Tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos (art. 26, § 7º): nas contratações destinadas à implantação, manutenção e aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País.

Nesse caso, somente poderão participar licitantes que ofertarem bens e serviços com tecnologia desenvolvida no Brasil.

- Utilização de mão de obra e insumos locais (art. 25, § 2º): desde que não sejam produzidos prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital de licitação poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução do contrato.

- Preferência para MEs e EPPs (art. 4º e art. 60, § 2º): a Lei Complementar n.º 123/2006, que institui o Estatuto das micro empresas e das empresas de pequeno porte, prevê tratamento privilegiado e simplificado para essas empresas, inclusive com preferências em licitações públicas.

Estudaremos essas preferências, de forma pormenorizada, adiante.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 4º Aplicam-se às licitações e contratos disciplinados por esta Lei as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º As disposições a que se refere o *caput* deste artigo não são aplicadas:

I - no caso de licitação para aquisição de bens ou contratação de serviços em geral, ao item cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte;

II - no caso de contratação de obras e serviços de engenharia, às licitações cujo valor estimado for superior à receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o *caput* deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação.

§ 3º Nas contratações com prazo de vigência superior a 1 (um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos nos §§ 1º e 2º deste artigo.

Art. 25. [...]

§ 2º Desde que, conforme demonstrado em estudo técnico preliminar, não sejam causados prejuízos à competitividade do processo licitatório e à eficiência do respectivo contrato, o edital poderá prever a utilização de mão de obra, materiais, tecnologias e matérias-primas existentes no local da execução, conservação e operação do bem, serviço ou obra.

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:

I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

§ 1º A margem de preferência de que trata o *caput* deste artigo:

I - será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal, no caso do inciso I do *caput* deste artigo;

II - poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadrem no disposto nos incisos I ou II do *caput* deste artigo;

III - poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados Partes do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República.

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País, definidos conforme regulamento do Poder Executivo federal, a margem de preferência a que se refere o *caput* deste artigo poderá ser de até 20% (vinte por cento).

§ 3º (VETADO).

§ 4º (VETADO).

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais se a capacidade de produção desses bens ou de prestação desses serviços no País for inferior:

I - à quantidade a ser adquirida ou contratada; ou

II - aos quantitativos fixados em razão do parcelamento do objeto, quando for o caso.

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.

Art. 60. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serão utilizados os seguintes critérios de desempate, nesta ordem:

I - disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta em ato contínuo à classificação;

II - avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigações previstos nesta Lei;

III - desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

IV - desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos órgãos de controle.

§ 1º Em igualdade de condições, se não houver desempate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços produzidos ou prestados por:

I - empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

II - empresas brasileiras;

III - empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

IV - empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

§ 2º As regras previstas no *caput* deste artigo não prejudicarão a aplicação do disposto no art. 44 da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Lei Complementar Nacional n.º 123/2006

Art. 44. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2º Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1º deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço.

Lei Nacional n.º 12.187/2009

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências.

2.5. Publicidade, Transparência e Sigilo das Propostas

a) Princípio da publicidade = divulgar: a publicidade é um princípio expressamente previsto no *caput* do art. 37 da CRFB/988, tendo o objetivo de garantir a qualquer interessado a possibilidade de participar e fiscalizar os atos do Poder público e, especificamente aqui, os atos da licitação.

Por intermédio da publicidade, a sociedade e os licitantes tomam conhecimento da realização do certame, podendo acessar as suas informações e fiscalizar todos os seus atos.

Exemplo: divulgação do edital de licitação em sítio eletrônico oficial e em outros meios para assegurar a publicidade e a ampla competitividade (art. 25, § 3º).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 25. [...]

§ 3º Todos os elementos do edital, incluídos minuta de contrato, termos de referência, anteprojeto, projetos e outros anexos, deverão ser divulgados em sítio eletrônico oficial na mesma data de divulgação do edital, sem necessidade de registro ou de identificação para acesso.

b) Princípio da transparência = informações claras: apesar de, muitas vezes, a publicidade e a transparência serem adotadas como termos sinônimos, há diferenças entre elas.

Publicidade é a qualidade de tornar o procedimento público e conhecido, ou seja, é o oposto ao sigilo. Por outro lado, a transparência é mais que isso: o Estado, além de divulgar a informação, deve divulgá-la em formato compreensível, claro, de fácil entendimento para a população.

Exemplo: divulgar preços de uma contratação é uma forma de concretizar a publicidade; mas divulgar essas informações em tabelas comparativas com os preços de mercado e de outras contratações é uma forma de concretizar a transparência.

c) Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) (art. 174): um dos maiores avanços no sentido da publicidade no âmbito das licitações é a instituição do PNCP, que será utilizado para:

- Divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;
- Realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os Entes federativos.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 174. É criado o Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), sítio eletrônico oficial destinado à:

- I - divulgação centralizada e obrigatória dos atos exigidos por esta Lei;
- II - realização facultativa das contratações pelos órgãos e entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de todos os entes federativos.

§ 1º [...]

d) Exceção: sigilo = segurança da sociedade e do Estado (art. 13, caput, e art. 91, § 1º): em que pese a publicidade seja a regra na licitação, esse dever não é absoluto – a Lei de Licitações dispõe que os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

No mesmo sentido, os contratos e seus aditamentos serão divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial, admitindo-se, entretanto, a manutenção em sigilo daqueles imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado – vide art. 5º, XXXIII, CRFB/1988.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. [...]

Art. 91. Os contratos e seus aditamentos terão forma escrita e serão juntados ao processo que tiver dado origem à contratação, divulgados e mantidos à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

§ 1º Será admitida a manutenção em sigilo de contratos e de termos aditivos quando imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, nos termos da legislação que regula o acesso à informação.

§ 2º [...]

CRFB/1988

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

e) Publicidade diferida (art. 13, púnico): há situações em que a publicidade será diferida, postergada, adiada, realizada em momento posterior.

- Conteúdo das propostas: quanto ao conteúdo das propostas, o sigilo é mantido até a respectiva abertura das propostas.

Trata-se do princípio do sigilo das propostas: nesse caso, a Administração recebe as propostas dos licitantes, mas não pode vazá-las antes da data da abertura, que ocorre na sessão pública de julgamento das propostas – essa conduta é tão importante que a nova Lei de Licitações criou um tipo penal específico no Código Penal, considerando crime a violação ao sigilo da proposta (art. 337-J, CP).

Exemplo: uma empresa vai participar de uma licitação na modalidade concorrência e tem o prazo até o dia “x” para registrar a sua proposta no sistema; se a Administração pública vazar essa proposta para outra empresa, esta terá vantagem sobre aquela.

Por isso, o conteúdo da proposta deverá ser mantido sob sigilo, até a data aprazada para a sua abertura, divulgação; contudo, após a abertura, as propostas tornam-se públicas.

- Orçamento: também pode ser mantido sigilo temporário quanto ao orçamento que a Administração pública realizou, ou seja, sobre o custo que ela apurou.

Como funciona isso? Durante a fase preparatória da licitação, uma das etapas compreende a elaboração do orçamento estimado. Isso serve para a Administração pública planejar-se, podendo identificar o valor aproximado do custo daquela obra, serviço, compra...

Nessa situação, há casos em que divulgar o orçamento aos licitantes não é interessante, já que os participantes saberão de antemão quanto aproximadamente a Administração está disposta a pagar e talvez apresentem a sua proposta em valores próximos ao do orçamento, ao invés de apresentarem valores conforme as suas reais condições.

Por isso há a possibilidade de tornar o orçamento estimado da contratação sigiloso; mas desde que haja justificativa.

Ainda assim, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. *Exemplo:* o Tribunal de Contas (controle externo) poderá solicitar os documentos do orçamento em uma auditoria.

Há situações, todavia, em que não é possível instituir o sigilo, como, por exemplo, quando o critério de julgamento for por maior desconto: aqui, obviamente, o preço estimado ou o máximo aceitável deverá constar do edital da licitação, pois os licitantes terão de ofertar um desconto sobre o valor de referência (estudaremos adiante).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 13. [...]

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

Código Penal

Violação de sigilo em licitação

Art. 337-J. Devassar o sigilo de proposta apresentada em processo licitatório ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo:

Pena - detenção, de 2 (dois) anos a 3 (três) anos, e multa.

2.6. Eficiência, Eficácia e Economicidade

Esses são princípios ligados ao desempenho das contratações.

a) Eficiência = relação custo/produto: a nova Lei de Licitações prevê expressamente o princípio da eficiência como forma de assegurar que as contratações públicas tenham como objetivo gerar resultados positivos à população.

A eficiência também diz respeito à relação entre os custos (insumos) e o produto, de modo que uma licitação é eficiente quando realizada em menos tempo, quando gasta menos recursos para a sua conclusão, quando obtém uma proposta com valores mais baixos...

Eficiência = custo/benefício ou insumo/produto.

b) Economicidade = reduzir custos: a economicidade diz respeito à minimização de custos, mas sem comprometer os padrões de qualidade.

Economicidade = minimização dos custos, mantidos os padrões de qualidade.

c) Eficácia = cumprir objetivos: a eficácia versa sobre o cumprimento dos objetivos da administração.

Exemplo: se o governo estipular como objetivo firmar três contratos de fornecimento de medicamentos ao longo do ano, haverá eficácia se todos os contratos forem efetivamente assinados.

2.7. Planejamento

As licitações e contratações deverão ser devidamente planejadas: isso busca evitar desperdícios e urgências indevidas.

a) Fase preparatória (art. 18, caput): a Lei de Licitações prevê a realização do planejamento da contratação durante a denominada fase preparatória – fase operacional ou administrativa do processo licitatório.

b) Plano de contratações anual (art. 18, § 1º, II): além disso, poderá existir um plano de contratações anual, que fará o alinhamento das contratações com o planejamento da Administração pública.

A partir de Documentos de Formalização de Demandas (DFD), os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades públicas sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias (art. 12, VII).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo poderão, na forma de regulamento, elaborar plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias.

Art. 18. A fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual de que trata o inciso VII do caput do art. 12 desta Lei, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos:

I - a descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracterize o interesse público envolvido;

II - a definição do objeto para o atendimento da necessidade, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico ou projeto executivo, conforme o caso;

III - a definição das condições de execução e pagamento, das garantias exigidas e ofertadas e das condições de recebimento;

IV - o orçamento estimado, com as composições dos preços utilizados para sua formação;

V - a elaboração do edital de licitação;

VI - a elaboração de minuta de contrato, quando necessária, que constará obrigatoriamente como anexo do edital de licitação;

VII - o regime de fornecimento de bens, de prestação de serviços ou de execução de obras e serviços de engenharia, observados os potenciais de economia de escala;

VIII - a modalidade de licitação, o critério de julgamento, o modo de disputa e a adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros, para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto;

IX - a motivação circunstanciada das condições do edital, tais como justificativa de exigências de qualificação técnica, mediante indicação das parcelas de maior relevância técnica ou valor significativo do objeto, e de qualificação econômico-financeira, justificativa dos critérios de pontuação e julgamento das propostas técnicas, nas licitações com julgamento por melhor técnica ou técnica e preço, e justificativa das regras pertinentes à participação de empresas em consórcio;

X - a análise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual;

XI - a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento da licitação, observado o art. 24 desta Lei.

§ 1º O estudo técnico preliminar a que se refere o inciso I do *caput* deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os seguintes elementos:

II - demonstração da previsão da contratação no plano de contratações anual, sempre que elaborado, de modo a indicar o seu alinhamento com o planejamento da Administração;

2.8. Segregação de Funções

a) Separar atribuições relevantes: segregar funções é separar atribuições relevantes, que envolvam riscos, especialmente para impedir que um mesmo agente público possa cometer um ilícito e ocultar a sua prática.

Portanto, a segregação de funções evita o acúmulo de funções por parte de um mesmo servidor – trata-se da separação das seguintes funções:

- *Autorização;*
- *Aprovação;*
- *Execução;*
- *Controle;*
- *Contabilização.*

Se o mesmo servidor público fosse encarregado de realizar o pedido, elaborar o edital, conduzir a licitação, firmar o contrato, atestar o recebimento do objeto, realizar o empenho, a liquidação e o pagamento, tendo controle sobre todas essas operações, ele teria muitos poderes concentrados, podendo cometer diversos ilícitos, os quais seriam facilmente escondidos por ele próprio.

A segregação não ocorre apenas em relação aos agentes públicos, ela também poderá envolver terceiros – *exemplo:* como já visto anteriormente, por vezes a empresa que elabora o projeto básico não pode participar da licitação ou da execução do contrato.

2.9. Motivação

a) Pressuposto de fato e de direito: a motivação é a indicação dos pressupostos de fato e de direito que levaram a Administração pública a tomar determinada decisão.

- *Pressuposto de fato:* o pressuposto de fato consiste na situação concreta, observada no mundo real.

- *Pressuposto de direito (tipicidade):* o pressuposto de direito consiste na previsão no ordenamento jurídico que fundamenta a decisão.

Exemplo: se a Administração pública que adquirir novos computadores, o pressuposto de fato será a necessidade dos mesmos, que deve ser demonstrada pelo órgão que realiza a solicitação; já o pressuposto de direito é a aquisição por meio por meio de um processo licitatório, pois a lei determina que a Administração pública deve comprar bens por meio desse procedimento.

2.10. Vinculação ao Edital

a) Edital = lei interna da licitação = regras previamente definidas: o edital define as regras do jogo – a vinculação ao edital significa que o processo licitatório deverá ser conduzido conforme as regras previamente definidas no edital da licitação.

É o edital quem define as regras do certame (art. 25).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 25. O edital deverá conter o objeto da licitação e as regras relativas à convocação, ao julgamento, à habilitação, aos recursos e às penalidades da licitação, à fiscalização e à gestão do contrato, à entrega do objeto e às condições de pagamento.

§ 1º [...]

b) Minuta do contrato: a minuta do contrato deve ser um dos anexos do edital de licitação, de modo que os licitantes possam verificar desde logo quais serão as regras da contratação.

c) Administração e licitantes: o princípio da vinculação ao edital vincula tanto a Administração pública quanto os licitantes.

2.11. Julgamento Objetivo

a) Objetividade do julgamento = eliminar a subjetividade: o princípio do julgamento objetivo indica que a Administração pública deverá analisar as propostas de forma objetiva, por meio de critérios de julgamento constantes no edital de licitação, restringindo ou eliminando a subjetividade, afastando preferências ou escolhas meramente pessoais dos responsáveis pelo julgamento das propostas.

O princípio do julgamento objetivo visa afastar o caráter discricionário quando da escolha das propostas do processo licitatório, obrigando os julgadores a se aterem aos critérios prefixados pela Administração pública, vedando que sejam utilizados critérios de julgamento reservados, sigilosos ou pessoais.

2.12. Segurança Jurídica

a) Estabilidade das relações jurídicas + uniformidade de entendimento: a segurança jurídica diz respeito à estabilidade das relações jurídicas constituídas.

No âmbito das licitações, este princípio tem aplicação relevante na fixação de entendimentos – os órgãos de controle e de assessoramento jurídico devem fixar os seus posicionamentos

de forma clara, emitindo orientações para pacificar as regras sobre a aplicação da legislação sobre licitações e contratos.

2.13. Razoabilidade e Proporcionalidade

a) Vedação aos excessos: os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são também conhecidos como princípio da vedação aos excessos – as limitações impostas pela Administração pública devem guardar correlação entre os meios e os fins.

Exemplos: uma exigência técnica deverá ser razoável, sob o ponto de vista de ser efetivamente necessária para o cumprimento do contrato, sem exageros; ao aplicar uma penalidade, a Administração pública deverá seguir uma proporção entre a gravidade da infração e o nível da sanção.

2.14. Celeridade

a) Prazo razoável: o princípio da celeridade significa que a licitação pública deverá ser realizada dentro de prazo razoável, sem demoras excessivas que possam prejudicar a realização da contratação e o atendimento do interesse público.

2.15. Desenvolvimento Nacional Sustentável

a) Perspectiva econômica e ambiental: o princípio do desenvolvimento nacional sustentável significa que as licitações públicas não se destinam apenas a selecionar propostas pelo aspecto econômico em sentido estrito; esse princípio significa que as contratações públicas devem buscar resguardar o desenvolvimento nacional sustentável sob as perspectivas econômicas e ambientais.

b) Flexibilização do princípio da isonomia: a proposta mais vantajosa nem sempre será aquela de menor preço. Em alguns casos, será justificável instituir preferências e benefícios para produtos e licitantes que atendam a critérios ambientais, e restrições para aqueles que não atendam.

Portanto, o princípio do desenvolvimento nacional sustentável flexibiliza a aplicação do princípio da isonomia, pois viabiliza contratações que atendam a outros critérios além do preço.

c) Margem de preferência (art. 26): admite-se a instituição de margem de preferência, que é a contratação por valor um pouco mais elevado, desde que presentes fatores como geração de emprego e renda no país, por meio da produção de bens e serviços manufaturados nacionais; utilização de bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis; e desenvolvimento e inovação tecnológica no país.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 26. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para:

I - bens manufaturados e serviços nacionais que atendam a normas técnicas brasileiras;

II - bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis, conforme regulamento.

§ 1º [...]

2.16. Princípios Implícitos ou Correlatos

Além dos princípios expressamente previstos na Lei de Licitações – vistos acima –, há outros princípios que decorrem da própria lógica do processo licitatório.

Veremos dois deles.

a) *Adjudicação compulsória*: o princípio da adjudicação compulsória é atribuir ao vencedor da licitação o seu objeto – é o ato pelo qual a Administração pública declara que, se vier a celebrar o contrato, o fará com o licitante vencedor da licitação.

A adjudicação compulsória ao vencedor impede que a Administração pública celebre o contrato com qualquer outro que não seja o legítimo vencedor.

- *Adjudicação X Assinatura do contrato*: esse princípio apenas dá direito à adjudicação, não garantindo a celebração, a assinatura do contrato.

Ele impede que o órgão público celebre o contrato com qualquer outra pessoa que não o vencedor da licitação; mas não garante que o contrato seja efetivamente assinado.

Isso ocorre porque pode ficar demonstrado, ao fim da licitação, que aquela contratação não é mais necessária, que não é mais viável...

b) *Formalismo procedimental e formalismo moderado*: é certo que a Administração pública deve seguir os ritos da lei, pois a ela se aplica – de modo amplo – o princípio da legalidade; porém, isso deve ocorrer sem excessos desnecessários.

- *Formalismo procedimental (burocracia)*: a licitação deve, sim, seguir o devido processo legal, respeitando o procedimento definido na Lei de Licitações (burocracia) – como regra, os atos do procedimento licitatório adotarão formato escrito e deverão ser publicados e divulgados (vide art. 12, I).

Mas a burocracia não deve ser exagerada (“burro-cracia”), pois o “*processo não é um fim em si mesmo*”.

- *Formalismo moderado (eficiência)*: o formalismo não deve ser absoluto, tanto que a longínqua EC n.º 19/1998, ao inserir no *caput* do art. 37 da CRFB/1988 o princípio da eficiência, substituiu a Administração pública burocrática pela gerencial.

É por isso que se adota o princípio do formalismo moderado, segundo o qual a Administração pública não deverá prender-se a formalidades exageradas que não contribuam para o atendimento do propósito das licitações e contratações públicas.

Veja-se o que dispõe o inc. III do art. 12 da Lei de Licitações: “*o desatendimento de exigências meramente formais que não comprometam a aferição da qualificação do licitante ou a compreensão do conteúdo de sua proposta não importará seu afastamento da licitação ou a invalidação do processo.*”

Exemplo: se um licitante enumerar de forma errada uma página da sua proposta, mas esse erro formal não comprometer a compreensão da mesma, a Administração pública não deverá desclassificá-lo (art. 59, I).

Na mesma linha, a autoridade superior somente declarará a nulidade dos atos que contiverem vícios insanáveis, podendo aproveitar aqueles que não forem comprometidos pelo ato viciado (art. 71, III e § 1º).

A Lei de Licitações também prevê outras regras para flexibilizar o formalismo – incs. IV, V e VI do art. 12.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte:

IV - a prova de autenticidade de cópia de documento público ou particular poderá ser feita perante agente da Administração, mediante apresentação de original ou de declaração de autenticidade por advogado, sob sua responsabilidade pessoal;

V - o reconhecimento de firma somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade, salvo imposição legal;

VI - os atos serão preferencialmente digitais, de forma a permitir que sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio eletrônico;

Art. 59. Serão desclassificadas as propostas que:

I - contiverem vícios insanáveis;

Art. 71. Encerradas as fases de julgamento e habilitação, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior, que poderá:

III - proceder à anulação da licitação, de ofício ou mediante provocação de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanável;

§ 1º Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicará expressamente os atos com vícios insanáveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que deles dependam, e dará ensejo à apuração de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

3. OBJETIVOS DA LICITAÇÃO

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no *caput* deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

a) Assegurar: resultado mais vantajoso (art. 11, I): a seleção da proposta deve estar atrelada ao resultado mais vantajoso, que nem sempre será a proposta com o menor valor financeiro.

A proposta mais barata pode parecer mais vantajosa inicialmente, mas os seus resultados podem não atender totalmente ao interesse público – é por isso, inclusive, que em alguns casos é possível estabelecer margem de preferência, pensando na geração de emprego, renda e desenvolvimento.

Importa, assim, o resultado mais vantajoso decorrente da contratação.

b) Assegurar: ciclo de vida do objeto (art. 11, I): o ciclo de vida refere-se à utilização do objeto ao longo do tempo.

Exemplo: ao comprar um veículo, a Administração deve considerar a manutenção, durabilidade, desvalorização, consumo...

Não basta olhar o preço e a qualidade do produto no momento da compra; há a necessidade de olhar para o futuro – esse é o ciclo de vida do objeto.

c) Assegurar: isonomia e justa competição (art. 11, II): as licitações também objetivam assegurar tratamento isonômico entre os licitantes e a justa competição entre eles.

d) Evitar: sobrepreço (art. 11, III, e art. 6º, LVI): o sobrepreço refere-se ao orçamento do objeto da licitação, o qual é acima do valor de mercado.

No sobrepreço, a Administração não sofre prejuízo, pois o objeto ainda não foi contratado nem pago: no sobrepreço não há dano ao patrimônio público.

Exemplo: os preços orçados para computadores de uma qualidade “X” são três vezes superiores aos preços praticados no mercado – apesar do sobrepreço, ainda não houve

prejuízo para o Poder público, pois os computadores não foram comprados (trata-se de mero orçamento).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

LVI - sobrepreço: preço orçado para licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado, seja de apenas 1 (um) item, se a licitação ou a contratação for por preços unitários de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou a contratação for por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada;

e) Evitar: superfaturamento (art. 11, III, e art. 6º, LVII): o superfaturamento pode se manifestar de diversas formas, sendo que nele sempre há dano ao patrimônio público.

Exemplo: a Administração pública paga por 100kg de arroz para merenda escolar, mas na verdade recebe apenas 80kg; paga por um uniforme escolar de excelente qualidade, mas recebe um produto de qualidade inferior.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

LVII - superfaturamento: dano provocado ao patrimônio da Administração, caracterizado, entre outras situações, por:

- a) medição de quantidades superiores às efetivamente executadas ou fornecidas;
- b) deficiência na execução de obras e de serviços de engenharia que resulte em diminuição da sua qualidade, vida útil ou segurança;
- c) alterações no orçamento de obras e de serviços de engenharia que causem desequilíbrio econômico-financeiro do contrato em favor do contratado;
- d) outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a Administração ou reajuste irregular de preços;

f) Evitar: preço inexecutável (art. 11, III, e art. 59, § 4º): ocorre quando o valor ofertado é sabidamente impossível de ser praticado por ser muito baixo, muito barato.

Ou seja, no preço inexecutável o licitante oferta um valor muito abaixo àquele praticado no mercado.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 59. [...]

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexecutáveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

g) Incentivar: inovação e desenvolvimento nacional sustentável (art. 11, IV): por fim, as licitações também visam incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Por isso que há preferências para ME's e EPP's, por exemplo.

4. AGENTES PÚBLICOS DA LICITAÇÃO

4.1. Agentes Públicos

a) Conceito: a própria Lei de Licitações apresenta o conceito do que é agente público para os seus fins, o qual é um pouco mais restrito que o conceito tradicional de agente público do Direito Administrativo.

Para a lei de licitações, agente público é somente aquele que desempenha suas funções em PJ integrante da Administração pública; para o Direito Administrativo, é qualquer pessoa física que exerça a função pública, não importando em qual entidade.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

V - agente público: indivíduo que, em virtude de eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, exerce mandato, cargo, emprego ou função em pessoa jurídica integrante da Administração Pública;

b) Requisitos (art. 7º): a Autoridade máxima do órgão ou da entidade – ou quem as normas de organização administrativa indicarem – deve realizar gestão por competências e designar agentes públicos capacitados para o desempenho das funções essenciais à execução das disposições da Lei de Licitações.

Isso vale para todos os agentes públicos que se envolverem nas licitações: agente de contratação, equipe de apoio e quaisquer outros.

Os requisitos mínimos são os que seguem.

- Preferencialmente: servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente.

- Qualificados: agentes públicos (i) que exerçam atribuições relacionadas a licitações e contratos; (ii) que possuam formação compatível; e/ou (iii) que possuam qualificação atestada (escola de governo).

- Sem parentesco nem vínculo: por fim, tais agentes públicos não devem possuir vínculo com os licitantes ou contratados habituais: (i) não podem ser cônjuge ou companheiro nem ter vínculo até terceiro grau; (ii) nem ter vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e/ou civil.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 7º Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade, ou a quem as normas de organização administrativa indicarem, promover gestão por competências e designar agentes públicos para o desempenho das funções essenciais à execução desta Lei que preencham os seguintes requisitos:

I - sejam, preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da Administração Pública;

II - tenham atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo criada e mantida pelo poder público; e

III - não sejam cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da Administração nem tenham com eles vínculo de parentesco, colateral ou por afinidade, até

o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil.

§ 1º [...]

c) Princípio da segregação das funções (art. 7º, §§ 1º e 2º): a Autoridade pública, quando faz a designação das funções entre os agentes públicos, deve observar o princípio da segregação das funções para evitar fraudes e outros.

Esse princípio já foi estudado alhures.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 7º [...]

§ 1º A autoridade referida no *caput* deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a riscos, de modo a reduzir a possibilidade de ocultação de erros e de ocorrência de fraudes na respectiva contratação.

§ 2º O disposto no *caput* e no § 1º deste artigo, inclusive os requisitos estabelecidos, também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da Administração.

4.2. Agente de Contratação

Agora vamos tratar especificamente do agente de contratação.

a) Obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado público do quadro permanente (art. 6º, LX): enquanto que os agentes públicos que atuam com licitação devem ser preferencialmente servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes, o agente de contratação obrigatoriamente deve ser efetivo (servidor público) ou do quadro permanente (empregado público).

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

LX - agente de contratação: pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

b) Agente de contratação conduz a licitação (art. 8º, caput): na nova Lei de Licitações, como regra, o papel de condução da licitação cabe ao agente de contratação, e não à comissão de licitação, como acontecia na Lei anterior (n.º 8.666/1993).

Mas, em alguns casos, a condução dos trabalhos caberá, sim, a uma comissão de contratação, como veremos logo abaixo.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da

licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

§ 1º ...

c) Equipe de apoio (art. 8º, § 1º): o agente de contratação será auxiliado por uma equipe de apoio, mas ele responde individualmente pelos atos que praticar, pois é ele quem tem o poder de decidir e, portanto, responderá pelos seus atos.

- Responsabilidade do agente de contratação: portanto, o agente de contratação responde sozinho pelos atos que praticar.

- Exceção = induzido a erro: a responsabilidade do agente de contratação somente será afastada se for induzido a erro pela atuação da equipe de apoio.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 8º [...]

§ 1º O agente de contratação será auxiliado por equipe de apoio e responderá individualmente pelos atos que praticar, salvo quando induzido a erro pela atuação da equipe.

d) Comissão de contratação = facultatividade = bem ou serviço especial (art. 6º, L, e art. 8º, § 2º): tratando-se de bens ou serviços especiais, o agente de contratação pode ser substituído por uma comissão de contratação.

- 3 membros: a comissão de contratação deve ser composta por, no mínimo, três membros.

- Preferencialmente efetivo ou do quadro: diferentemente do agente de contratação, os membros da comissão de contratação serão apenas preferencialmente servidores públicos efetivos ou empregados públicos do quadro permanente.

- Responsabilidade solidária: os membros que compõem a comissão de contratação responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão.

- Exceção: somente não responderá pelo ato o membro que expressar posição individual divergente, a qual deve ser fundamentada e registrada em ata.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

L - comissão de contratação: conjunto de agentes públicos indicados pela Administração, em caráter permanente ou especial, com a função de receber, examinar e julgar documentos relativos às licitações e aos procedimentos auxiliares;

Art. 8º [...]

§ 2º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 7º desta Lei, o agente de contratação poderá ser substituído por comissão de contratação formada por, no mínimo, 3 (três) membros, que responderão solidariamente por todos os atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião em que houver sido tomada a decisão.

e) Comissão de contratação = obrigatoriedade = diálogo competitivo (art. 32, § 1º, XI): tratando-se de licitação na modalidade diálogo competitivo, ela obrigatoriamente será conduzida por comissão de contratação.

- 3 membros: a comissão de contratação deve ser composta por, no mínimo, três membros.

- Obrigatoriamente efetivo ou do quadro: além do mais, os membros desta comissão de contratação devem ser, obrigatoriamente, servidores públicos efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração pública.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 32. [...]

§ 1º Na modalidade diálogo competitivo, serão observadas as seguintes disposições:

XI - o diálogo competitivo será conduzido por comissão de contratação composta de pelo menos 3 (três) servidores efetivos ou empregados públicos pertencentes aos quadros permanentes da Administração, admitida a contratação de profissionais para assessoramento técnico da comissão;

f) Empresa ou profissional especializado = bem ou serviço especial não rotineiro (art. 8º, § 4º): tratando-se de bens ou serviços especiais que não sejam rotineiramente contratados pela Administração pública, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado, que irá assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

Exemplo: contratação de um projeto arquitetônico específico.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 8º [...]

§ 4º Em licitação que envolva bens ou serviços especiais cujo objeto não seja rotineiramente contratado pela Administração, poderá ser contratado, por prazo determinado, serviço de empresa ou de profissional especializado para assessorar os agentes públicos responsáveis pela condução da licitação.

4.3. Assistência Jurídica para Autoridade e Agentes Públicos

Um exemplo ajuda a compreender essa situação: imagine-se que um agente público foi designado para atuar em licitações e contratos e, apesar de tomar as suas decisões com base em um parecer jurídico emitido pela advocacia pública, passa a responder em virtude de ter cometido uma irregularidade.

Perceba-se que esse agente público, apesar de ter atuado conforme orientação realizada pela advocacia pública, terá que arcar com os custos de um processo para se defender, inclusive contratando advogado.

É nessa situação que esse agente público poderá optar em ser defendido, sem custos, pela própria advocacia pública – art. 10, Lei Nacional n.º 14.133/2021.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 10. Se as autoridades competentes e os servidores públicos que tiverem participado dos procedimentos relacionados às licitações e aos contratos de que trata esta Lei precisarem defender-se nas esferas administrativa, controladora ou judicial em razão de ato praticado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico

elaborado na forma do § 1º do art. 53 desta Lei, a advocacia pública promoverá, a critério do agente público, sua representação judicial ou extrajudicial.

§ 1º Não se aplica o disposto no caput deste artigo quando:

I - (VETADO);

II - provas da prática de atos ilícitos dolosos constarem nos autos do processo administrativo ou judicial.

§ 2º Aplica-se o disposto no caput deste artigo inclusive na hipótese de o agente público não mais ocupar o cargo, emprego ou função em que foi praticado o ato questionado.

Art. 53. Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da Administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação.

§ 1º Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da Administração deverá:

I - apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade;

II - redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica;

III - (VETADO).

a) Estrita observância de parecer jurídico: as Autoridades e os agentes públicos somente poderão valer-se da defesa por meio da advocacia pública se os atos pelos quais estiverem respondendo foram praticados em estrita observância do que constava no parecer jurídico.

b) Esferas administrativa, controladora e/ou judicial: essa atuação da advocacia pública em favor da autoridade e/ou agente público pode ser tanto na esfera administrativa (processo administrativo), controladora (junto ao Tribunal de Contas) ou judicial (perante o Poder Judiciário).

c) A critério do agente público: quem decide se quer utilizar a advocacia pública para atuar em seu favor é a própria autoridade ou agente público que tem de defender-se.

Se eles quiserem, podem preferir contratar advogado próprio.

5. MODALIDADES DE LICITAÇÃO

5.1. Noções Gerais

a) Modalidade = procedimento: as modalidades de licitação definem o procedimento da licitação, ou seja, o rito, o caminho, as etapas da realização da licitação pública.

Não confundir as modalidades de licitação com os critérios de julgamento (estes eram chamados de tipos de licitação na lei anterior).

b) Natureza do objeto define a modalidade: as modalidades de licitação são definidas com base na natureza do objeto, e não mais com base no valor da contratação (isso ocorria na lei anterior).

Exemplo: para vendas de bens públicos, a modalidade de licitação sempre será o leilão, independentemente do valor; para a compra de bens e de serviços comuns, sempre se utilizará a modalidade pregão; da mesma forma, a modalidade concurso sempre será utilizada para a escolha de trabalhos técnicos, científicos ou artísticos, não importando o valor.

c) Modalidades: as modalidades de licitação previstas na nova lei de licitações são as seguintes:

- Pregão;
- Concorrência;
- Concurso;
- Leilão;
- Diálogo competitivo.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 28. São modalidades de licitação:

- I - pregão;
- II - concorrência;
- III - concurso;
- IV - leilão;
- V - diálogo competitivo.

§ 1º Além das modalidades referidas no *caput* deste artigo, a Administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no art. 78 desta Lei.

§ 2º É vedada a criação de outras modalidades de licitação ou, ainda, a combinação daquelas referidas no *caput* deste artigo.

d) Vedado criar e/ou combinar (art. 28, § 2º): é expressamente vedado criar outras modalidades de licitação e/ou combinar as modalidades existentes.

5.2. Concorrência

A concorrência é a modalidade de licitação utilizada para a contratação de bens e serviços especiais, obras e serviços de engenharia (comuns e especiais), podendo ser utilizado qualquer critério de julgamento (menos o critério maior lance) – art. 6º, XXXVIII.

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XXXVIII - concorrência: modalidade de licitação para contratação de bens e serviços especiais e de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, cujo critério de julgamento poderá ser:

- a) menor preço;
- b) melhor técnica ou conteúdo artístico;
- c) técnica e preço;
- d) maior retorno econômico;
- e) maior desconto;

a) Bens e serviços especiais (art. 6º, XIV): bens e serviços especiais são aqueles que não são comuns.

Portanto, a conceituação de bens e serviços especiais é residual, ou seja, são bens e serviços especiais aqueles que não são comuns – para bens e serviços comuns deve-se utilizar o pregão (quando estudarmos pregão, definiremos bens e serviços comuns).

A Lei de Licitações dispõe que bens e serviços especiais são aqueles que, "por sua alta heterogeneidade ou complexidade", não podem ser descritos como comuns (art. 6º, XIV) – a Administração pública terá de fundamentar porque determinado bem ou serviço não são comuns.

Características dos bens e serviços especiais:

- *Não são comuns;*
- *Alta heterogeneidade OU complexidade;*
- *Não há como descrevê-los objetivamente.*

Lei Nacional n.º 14.133/2021

Art. 6º Para os fins desta Lei, consideram-se:

XIII - bens e serviços comuns: aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado;

XIV - bens e serviços especiais: aqueles que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade, não podem ser descritos na forma do inciso XIII do *caput* deste artigo, exigida justificativa prévia do contratante;

b) Obras (art. 6º, XII): o que é obra para os fins da nova lei de licitações é algo bastante técnico, pois elas são privativas de arquiteto ou engenheiro, implicam intervenção no meio ambiente e inovam o espaço físico ou alteram substancialmente um bem imóvel.

Características das obras:

- *Privativas de arquiteto ou engenheiro;*
- *Inovam o espaço físico da natureza OU alteram substancialmente um imóvel.*